

1501762-04.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que "... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

4ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501762-04.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501762-04.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2245579/2021 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 20141630 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3039/21/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2245579 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NAYRAN DA SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

NAYRAN DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na denúncia à qual me reporto (fls. 71/72).

Oferecida a denúncia (fls. 73/74), esta foi recebida (fls. 75/77) e o réu devidamente citado.

Após a apresentação de defesa escrita (fls. 100/101), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 109).

Durante a instrução foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais orais.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem apreciadas.

E, no mérito, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou o delito que lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo químico toxicológico (fls. 94/96), que atesta pelos resultados positivos para cocaína e maconha, pelo relatório final (fls. 62/65), bem como pela prova oral nos autos produzida.

De fato, os Policiais Civis Pedro Paulo Bassetti e Bruno Sturari Scarpelli, quando inquiridos em juízo, disseram que foram até o local dos fatos, que é ponto conhecido em razão da traficância, onde realizaram breve campana.

A empreitada policial foi realizada a aproximadamente 30 metros do local e perdurou por volta de 30 minutos, segundo o agente Bruno, ouvido em juízo.

Asseveraram que observaram o acusado servindo drogas para usuários. Diante disso efetuaram a abordagem e, dentro da bolsa que o réu levava consigo, encontraram os entorpecentes apreendidos (20 porções de crack e 143 de maconha).

Aduziram que não conhecem o réu e que na ocasião o acusado confessou a prática do delito. Ainda, o policial Pedro disse que o acusado disse que estava desempregado.

E a fala dos policiais, contra quem nada se levantou, foram harmônicas e isentas de contradições, se cotejadas com os depoimentos prestados, por eles, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria. E o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria

sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

"Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum" (in "Jurisprudência Penal e Processual Penal", AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

O réu, quando interrogado, negou a prática do crime, dizendo que passava pelo local dos fatos porque um amigo mora nas imediações.

Pois bem.

A imputação Ministerial é passível de acolhimento porque restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas que o acusado, de fato, estava a praticar a traficância juntamente, pois levava consigo expressiva quantidade de entorpecentes.

Isso porque está clara a prática do que traz o tipo previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos, qual seja, o tráfico de entorpecentes, por parte do réu, na medida em que levava consigo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ora, os entorpecentes, em expressiva quantidade e variedade eram levados pelo réu, que os detinha especialmente para o fim de cometer a traficância.

Os depoimentos prestados pelos agentes foram uníssonos e harmônicos ao descreverem as diligências realizadas durante o ocorrido.

A propósito, o fato de o réu levar os entorpecentes é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, na medida em que "... para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante ..." (Apelação Criminal nº 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques da Silva).

Assim, diante dos elementos de convicção e das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo sua condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno NAYRAN DA SILVA GOMES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Na primeira fase da dosagem, majoro a pena do acusado em 1/6 (um sexto), pois há de se anotar que a conduta do requerido é mais reprovável do que a normal à espécie.

Com efeito, a expressiva quantidade e variedade de drogas encontradas com o réu seriam vendidas em porções fracionadas, de sorte que atingiriam muitas pessoas.

Assim, sua culpabilidade, diante disso, é mais acentuada.

Com efeito, tal entendimento foi confirmado no r. acórdão proferido nos autos de nº 0001381-11.2015.8.26.0360, com relação à sentença de lavra deste julgador:

“Em detida análise dos autos, de rigor o reconhecimento da pena-base acima do mínimo legal.

Ressalte-se que embora este Relator perfilhasse do entendimento que a quantidade da droga apreendida serviria para caracterizar o delito do tráfico de drogas, mas não era suficiente à exacerbação da pena-base, após minuciosa análise sobre o tema, filio-me ao entendimento de que a quantidade e natureza da droga, neste caso, recomendam a fixação acima do mínimo, o que é permitido pelo artigo 42, da Lei de Drogas.

O artigo 42, da Lei 11.343/06 prevê, de forma expressa, que na fixação das penas o Juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal: 'a quantidade da substância ou do produto', de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser considerado para agravar a pena.

Sobre o tema a seguinte jurisprudência:

'A natureza e a quantidade da droga são fatores que, na fixação da pena-base no crime de tráfico, preponderam sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, e justificam o aumento da pena-base acima do mínimo legal.' (STJ. HC 155.128/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2011, GJe 14/11/2011).

Porquanto, a quantidade de droga apreendida, frisa-se, justifica a exasperação da pena-base, assim como também entendeu o d. Magistrado a quo.” (TJSP - APELAÇÃO nº 0001381-11.2015.8.26.0360, 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, Rel. Paulo Rossi, julgado em 19/10/2016).

Na segunda fase, verifico a existência da atenuante relativa à menoridade relativa, tendo em vista que o réu, à época dos fatos, era menor de 21 anos (art. 65, inciso I, do CP), motivo pelo qual reduzo a pena do acusado em 1/6, anotando-se, contudo, o teor da Súmula 231 do STJ, no sentido de que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

E, na terceira fase, não há nada a ser considerado.

Ainda, o acusado não tem direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide ao caso concreto.

Isso porque o réu levava consigo expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância que indica que está efetivamente inserido em atividade organizada.

Deveras, “porque diante da apreensão de considerável quantidade de drogas, inequivocamente destinadas ao comércio, admitindo-se a atividade ilícita, o delito cometido se afigura como típico e intrínseco à criminalidade organizada, ressabido que não há, ainda, “livre concorrência” ou “empreendedorismo” no tráfico. Sendo evidente que os responsáveis pela estruturação da venda de drogas, já estando no controle das etapas de produção, transporte e acondicionamento, não confiariam a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos a pessoa que não gozasse da confiança deles, ou não tivesse com eles algum vínculo”.

Isso demonstra que o acusado tem se dedicado a atividade criminosa, circunstância apta a afastar a possibilidade de aplicação da causa de redução em comento.

E é evidente que a benesse penal em questão é dirigida a pessoas que se envolveram com a traficância de forma pontual, ocasional, hipótese com a qual, repita-se, não se identifica o caso vertente.

Nesse sentido, verifique-se o seguinte trecho do excelente voto condutor prolatado pelo Excelentíssimo Desembargador Geraldo Wohlers, em v. acórdão que confirmou

condenação proferida por este magistrado, na Comarca de Serrana:

“A diminuição hoje admitida pelo parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade do agente. O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se dedique às atividades criminosas”.

Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico. A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

No âmbito desta Colenda Câmara, consignou o preclaro DES. LUIZ ANTONIO CARDOSO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 990.09.111160-0 (Comarca de Lucélia, j. em 25 de maio de 2010), que “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder”.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33. Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de “não se dedicar às atividades criminosas” (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente...

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante)”. (TJ/SP; Ap. 0003339-42.2011.8.26.0596; OJ 3ª Câmara de Direito Criminal: DJ 04/12.12) (destaquei)

Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedica a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela.

Assim, chego, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo

vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, diante da gravidade do delito em questão, da pena aplicada e diante dos veementes indicativos de que o réu está incisivamente inserido na traficância, uma vez que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes.

Nesse sentido, inclusive, se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que diante das particularidades do caso concreto e da apreensão de grande quantidade de drogas é possível afastar a figura do tráfico privilegiado e fixar regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas. Vale dizer, a elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas.

2. A Corte estadual considerou indevida a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, "dada a grande quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes", circunstância que, de fato, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

3. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juizes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que "diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão." Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente.

Pelas mesmas razões, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à concessão do "sursis".

Deveras, tais benefícios não são compatíveis, concretamente, com a necessária reprovação e a indispensável prevenção da conduta incriminada.

Afinal, como é sabido, a pena além de ressocializadora deve servir para prevenção geral e específica, de modo que a reprimenda aplicada venha a inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como repreensão ao delinquente (prevenção específica).

Assim sendo, a pena aplicada deve ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apesar da edição da Resolução 5/2012 do Senado Federal suspendendo a execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direito” do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, baseio-me no entendimento no sentido de que o art. 44 da Lei de Drogas não está suspenso, bem como de que a proibição da substituição fia-se no art. 5º, inciso LXIII da Constituição Federal, na medida em que, mesmo se tratando de tráfico de drogas sem majorantes, a hediondez do delito não está afastada.

Não bastasse isso, é de se ter em conta que seria um verdadeiro absurdo que, concretamente, fosse a pena privativa de liberdade substituída por outra restritiva de direitos, já que isso tornaria possível que uma pessoa condenada por tal crime prestasse serviços a comunidade p.ex. em uma escola - onde fatalmente teria farta clientela - ou em um hospital, onde teria grande quantidade de substância entorpecente muito próxima.

Por isso, com a devida vênia dos que pensam diferentemente, repudio o entendimento de que, a não ser em casos específicos e isolados, tal substituição seja possível, ainda quando a quantidade de pena concretamente imposta não seja suficiente para afastar o benefício.

Impossível a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois não há informação nos autos sobre eventuais prejuízos financeiros experimentados pela sociedade.

Se a providência já não foi deferida, autorizo, agora, a destruição da droga apreendida.

Nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento de dinheiro e objeto apreendidos, se o caso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que assim permaneceu durante a instrução do feito.

Nome no rol, oportunamente.

Ao defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidão, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P.I.C.

Itapeccerica da Serra, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA